



ANALISTA
DIREITO PENAL
SILVIO MACIEL
AULA 8

ROTEIRO DE AULA

Sumário

tema: concurso de pessoas

8. comunicabilidade das elementares e circunstâncias do crime (art. 30 cp)

9. casos de impunibilidade (art. 31)

10. autoria colateral (coautoria imprópria ou autoria aparelha) e autoria incerta

tema: teoria da pena

1 – sanção penal

2 – princípios da pena

3 – teorias da pena (finalidades)

4- penas privativas de liberdade

CONCURSO DE PESSOAS (art. 29 a 31)

8. Comunicabilidade das elementares e circunstâncias do crime (art. 30 CP)

Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

Elementares (dados essenciais do crime)

- Ausente uma elementar, não existe o crime
- ex. coisa alheia móvel; se não for alheia ou móvel, não há furto
- Podem ser
 - a) Objetivas – meios ou modos de execução do crime
 - b) Subjetivas – motivos ou condições pessoais do sujeito ativo
- Elementares se comunicam aos coautores ou partícipes, desde que ingressem no dolo (tenham conhecimento da elementar)
- ex. condição de funcionário público é elementar do peculato (art. 312) – elementar subjetiva que se transmite ao particular, desde que saiba que o comparsa é funcionário público

Circunstâncias (dados relacionados com a pena)

- Não interferem na existência do crime; apenas na dosagem
- ex. qualificadores; causas de aumento e diminuição; agravantes e atenuantes
- Podem ser
 - a) Objetivas – meios ou modos de execução do crime
 - ❖ COMUNICAM desde que ingressem no dolo (tenham conhecimento da circunstância)
 - ❖ ex. veneno – qualificadora do crime de homicídio – A e B combinam de matar uma vítima; A empresta arma para B; B ao invés de usar a arma, decide empregar veneno para matar; a qualificadora veneno não se transmite ao coautor A (o combinado era matar com arma)
 - ❖ Se A sugerir o uso do veneno e B utilizar, haverá comunicação
 - b) Subjetivas – motivos ou condições pessoais do sujeito ativo
 - ❖ Nunca se comunicam

9. Casos de impunibilidade (art. 31)

Art. 31 - O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.

Cogitação e preparação:

- Ajuste
- Instigação
- Auxílio
- Nesses casos, se o crime não chega nem a ser tentado, serão considerados mera cogitação ou preparação (não chega na execução) –não sendo puníveis
- ex. duas pessoas combinam de roubar um banco, mas nunca roubam (ajuste que não chega na execução)
- ex. vizinho dá veneno para o outro colocar na bebida da esposa (auxílio material); esse vizinho nunca chega a utilizar a substância; auxílio não passa de ato preparatório
- ex. vizinho empresta para A uma arma raspada para matar a esposa; A pega a arma e guarda e nunca mata a esposa; o fato de emprestar arma raspada, por si só, configura porte ilegal de arma; embora o crime de homicídio não tenha sido tentado, o auxílio já configura crime (aqui se encaixa a expressão “salvo disposição em contrário”)

10. Autoria Colateral (coautoria imprópria ou autoria aparelha) e Autoria Incerta

Primeiramente, recorde os requisitos cumulativos do Concurso de Pessoas:

- a) Pluralidade de agentes imputáveis;
- b) Nexo Causal das várias condutas; (processo hipotético de eliminação)
- c) Homogeneidade de Elemento Subjetivo; (TODOS agindo com dolo ou culpa)
- d) **Liame Subjetivo**; (adesão da conduta de uma pessoa pela outra, que NÃO se trata de prévio ajuste)
- e) Identidade de Infrações. (Todos os agentes respondem pelo mesmo crime)

Bloco 2

Agora, entenda o significado de:

- **AUTORIA COLATERAL** = extrema coincidência, onde os criminosos executam, simultaneamente, suas condutas sem que um saiba da existência da conduta do outro. Ex: dois matadores de aluguel estão escondidos em prédios diferentes, aguardando a vítima passar para matá-la, e, no momento que a vítima aparece, ambos atiram e atingem a vítima ao mesmo tempo, **entretanto**, um não sabia da conduta do outro (AUSÊNCIA DO LIAME SUBJETIVO).

ex.2. um matador atira e mata e outro atira e erra; um crime de homicídio consumado e outro tentado; não se sabe qual matador acertou e qual errou; ambos respondem por homicídio tentado (in dubio pro reo)

ex.3 ambos atiram e acertam a vítima; perícia detecta que A acertou o tiro e B acertou depois da morte; B não cometeu crime (atirar em cadáver é crime impossível por absoluta impropriedade do objeto)

- **AUTORIA INCERTA** = ocorre dentro da autoria colateral, e se dá quando não se sabe qual dos infratores consumou o crime.

Importante: a autoria incerta não se confunde com a **AUTORIA IGNORADA**/DESCONHECIDA, porque nessa modalidade não se sabe quem é o autor do crime, e, por sua vez, naquela, a autoria é conhecida, porém não se sabe qual dos infratores consumou o crime

11. concurso de pessoas em crimes culposos

Para a maioria da doutrina, cabe apenas coautoria em crime culposo e não cabe participação

Coautoria existe (sem dúvidas): ex. dois pedreiros jogam tábua do último andar do prédio; a tábua acerta uma pessoa e mata; ambos são coautores de crime culposo

ex. passageiro pede para motorista exceder a velocidade; motorista mata alguém; não existe participação em crime culposo; cada um é autor de sua própria imprudência; passageiro é autor de homicídio por imprudência

Tema: TEORIA DA PENA

1 – Sanção Penal

Pena (1ª Via) e Medida de Segurança (2ª Via). A 3ª Via ocorre quando a sanção penal é substituída pela reparação do dano. Por exemplo, no caso da composição civil de danos prevista no JECRIM.

2– Princípios da Pena

a) Princípio da reserva legal da estrita legalidade

b) Princípio da anterioridade

c) Princípio da personalidade, intransmissibilidade, intranscendência ou responsabilidade pessoal: de acordo com o artigo 5º, XLV da CF a pena não pode ser imposta ou executada contra terceiros, nem mesmo a pena de multa. Entretanto, a obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens são efeitos da condenação e não são penas, razão pela qual podem ser estendidos aos sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido (art. 5º, XLV)

d) Princípio da inderrogabilidade ou da inevitabilidade: o juiz não pode deixar aplicar a pena; esse princípio é excepcionado por alguns institutos como, por exemplo, a prescrição e o perdão judicial.

e) Princípio da intervenção mínima: decorre dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade já estudados (direito penal somente interfere quando outros ramos do direito não são suficientes)

f) Princípio da humanidade ou humanização das penas: as penas não podem violar a integridade física ou moral do preso e não podem constituir tratamento cruel, desumano, ou degradante, sendo proibida as penas de morte, perpétuas, de trabalhos forçados ou de banimento.

g) Princípio da proporcionalidade: penas devem ser previstas e aplicadas conforme a gravidade do crime e condições pessoais do infrator; aplica-se tanto no plano abstrato, como barreira ao legislador para a previsão de penas excessivas, quanto no plano concreto, como baliza para o magistrado na dosimetria da pena.

h) Princípio da individualização da pena: pena deve ser aplicada de forma individualizada conforme as condições pessoais do infrator; conforme decisão do STF e conforme entendimento da jurisprudência esse princípio se aplica nos planos legislativo, judicial e administrativo (executório)

3 – Teorias da Pena (finalidades)

As teorias da pena na verdade têm por objetivo justificar as finalidades da pena.

3.1. Teoria absoluta (finalidade retributiva): a pena não tem nenhuma finalidade específica, nem mesmo de recuperação social do infrator. Tem apenas o objetivo de castigar o infrator pelo mal causado. Apenas significa castigar o mal causado com outro mal. Trata-se de instrumento de vingança estatal contra o criminoso.

3.2. Teoria relativa (finalidades preventivas): a pena tem a finalidade de prevenir novas infrações. Tem a finalidade de prevenção geral positiva e negativa e de prevenção geral especial positiva e negativa.

3.2.1. Prevenção geral negativa (Feurbach): *tem a função de desestimular na sociedade o cometimento de novos crimes, intimidando os cidadãos pelo exemplo da pena aplicada àquele que cometeu infração (teoria da coação psicológica de Feurbach). O criminoso é usado de exemplo para os demais cidadãos (direito penal do terror).*

3.2.2. Prevenção geral positiva: a pena tem a finalidade de reafirmar a existência, a validade e a eficiência do direito penal. Visa reforçar a confiança do povo na firmeza e no poder de execução do ordenamento jurídico por parte do Estado.

3.2.3. Prevenção especial negativa: a pena tem a finalidade específica de intimidar o condenado e desestimulá-lo a reincidir.

3.2.4. Prevenção especial positiva: a pena deve visar a ressocialização do condenado. A pena só é legítima e útil se for capaz de promover essa ressocialização. Atualmente tem se sustentado que a pena, além de socializadora, deve ser não dessocializadora, ou seja, além de garantir o retorno ao convívio social, deve ainda minimizar no máximo possível a marginalização e os efeitos criminosos que a prisão causa ao indivíduo.

3.3. Teoria mista ou unificadora: dupla finalidade de retribuição e prevenção (**Teoria da união eclética, intermediária, conciliatória ou unitária**)

É a fusão das teorias anteriores. A pena tem uma tríplice função: punir o indivíduo pelo mal causado, desestimular o próprio indivíduo a cometer novos crimes e desestimular a sociedade a cometer crimes usando o criminoso punido como exemplo.

É a teoria adotada pelo artigo 59 do Código Penal que dispõe que a pena deve ser aplicada para **reprovação e prevenção** do crime.

O STF já decidiu que a reabilitação individual do condenado é uma finalidade da pena que deve ser buscada tanto pelo próprio encarcerado quanto pelo Estado, num esforço conjunto (HC 91.874).

3.4. Teoria agnóstica (teoria negativa): baseada na descrença das finalidades da pena. Para essa teoria as finalidades da pena acima apontadas são apenas ideários jamais alcançados na prática. Logo, a única função realmente concreta da pena é a neutralização do condenado com o seu afastamento da sociedade, ainda que temporário.

3.5. Teoria social da pena ou função social da pena: a crise do sistema carcerário faz com que a pena seja mero castigo e não atinja as suas pretendidas finalidades. A verdadeira finalidade da pena deve ser proteger e pacificar a sociedade tutelando os bens jurídicos indispensáveis para a manutenção e o desenvolvimento das pessoas e da coletividade. Ao mesmo tempo a pena só será legítima de acordo com a racionalidade contemporânea evitando que o delinquente se torne um instrumento de sentimentos ancestrais de represália e castigo. Só assim ela pode tentar cumprir sua função ressocializadora e preventiva.

Bloco 3

Obs. – Fundamentos da pena

Os fundamentos são os motivos que justificam e legitimam a pena. Por isso não se confundem com a finalidade da pena. A doutrina aponta seis fundamentos:

a) retribuição: a pena é a forma justa e humana que a sociedade tem de punir seus indivíduos

b) reparação: relaciona-se com a vitimologia, pois a pena permite a reparação à vítima do crime ou aos seus familiares

c) denúncia: o objetivo da pena é buscar a prevenção geral por meio da intimidação coletiva

d) incapacitação: a pena visa isolar o indivíduo infrator do convívio social para que possam ser protegidas as pessoas de bem. Embora a pena possa parecer uma mera punição (retribuição), na verdade o que se pretende é proteger as demais pessoas do infrator

e) reabilitação: a pena é aplicada para que se tente reestruturar o indivíduo infrator e devolvê-lo a sociedade

f) dissuasão: o motivo da pena é demonstrar para as pessoas que o crime não compensa

Abolicionismo Penal

Tem origem na Holanda com Louk Hulsman e na Noruega com Nils Christie e Thomas Mathiesen.

É uma forma nova de pensar o direito para resolver o problema da crise da pena.

Consiste em descriminalizar determinadas condutas, despenalizar outras condutas e residualmente diminuir consideravelmente as penas dos crimes de maior gravidade.

Essa teoria parte de uma constatação: uma ínfima parcela dos crimes é efetivamente punida (cifra negra), e uma ínfima parcela dos indivíduos que são punidos efetivamente cumprem a pena. E quase nenhum indivíduo que cumpria pena deixa de reincidir ou efetivamente se ressocialização. Assim sendo a sociedade tem mecanismos para suportar a criminalidade sem precisar do direito penal, que na verdade já é o que ocorre na prática.

O problema penal deve ser enfrentado por outros mecanismos como, por exemplo, com a utilização de recursos públicos para atendimento das vítimas e não para a construção de mais presídios que para nada servem.

O próprio abolicionismo penal possui divisões:

Abolicionismo fenomenológico (Louk Hulsman): o sistema penitenciário é um problema em si mesmo. É uma inutilidade incapaz de fato resolver os problemas de criminalidade. O sistema penitenciário deve ser abolido totalmente porque serve apenas para criar sofrimento desnecessário com efeitos irreversíveis para quem é lançado nesse sistema e que em contrapartida não produz nenhuma finalidade para a sociedade. O crime é um problema social que deve ser resolvido por instâncias intermediárias sem natureza penal.

Abolicionismo fenomenológico-historicista (Nils Christie e Thomas Mathiesen): o sistema penal é fruto da distorção do sistema capitalista. O sistema penal deve ser totalmente eliminado assim como qualquer meio de repressão existente na sociedade. O direito deve se esforçar por limitar a dor e não por impor dor a outras pessoas.

O abolicionismo penal é considerado pela maioria como utopia.

Justiça negociada

É o *plea bargaining* do direito anglo-saxão, surgido no direito norte-americano.

Tem como pressuposto a admissão da culpa. Uma vez admitida a culpa o órgão acusatório e o infrator firmam acordo sobre as consequências jurídicas da conduta criminosa.

Esse acordo pode envolver não somente a pena a ser aplicada como eventuais efeitos da condenação, como por exemplo, o confisco de bens ou o valor da reparação do dano para a vítima.

No Brasil são exemplos de justiça negociada o Acordo de Não Persecução Penal e a Colaboração Premiada.

Teoria das Janelas Quebradas (*Broken Windows Theory*)

1969 – Universidade de Stanford – Phillip Zimbardo

Numa pesquisa de psicologia social o professor e seu grupo deixaram dois carros iguais intactos: um no Bronx em Nova Iorque e outro em Palo Alto na Califórnia. O carro deixado no Bronx foi imediatamente destruído e saqueado enquanto o carro mantido em Palo Alto ficou intacto. Entendeu-se que a pobreza é o fator determinante da criminalidade. Na sequência quebraram a janela do carro que estava em Palo Alto e após isso ele foi imediatamente quebrado e saqueado. Concluiu-se que o fator determinante da criminalidade não é a pobreza, em si mesma, mas a sensação de impunidade.

1982 - James Wilson e George Kelling desenvolveram a teoria das janelas quebradas no campo da criminologia.

Essa teoria sustenta que a maior incidência de crimes ocorre numa comunidade que demonstra descuido e desordem e sinais de deterioração e que não se importa com isso. Assim sendo, se a pequena criminalidade soa indiferente para a comunidade (pequenos furtos, por exemplo) ela abre espaço para o cometimento de crimes mais graves.

Essa teoria foi aplicada no metrô de Nova Iorque que era um dos locais mais deteriorados e perigosos da cidade. Foram combatidas as pequenas infrações como, por exemplo, pichações, consumo de álcool, não pagamentos de passagens e isso se mostrou absolutamente eficaz e certo. O local passou a ser limpo e seguro.

Essa teoria foi aplicada pelo prefeito de Nova Iorque Rudolph Giuliani, em 1994, com a política de tolerância zero a qualquer violação da lei independentemente do seu grau.

Essa teoria é constantemente relacionada com a teoria dos testículos quebrados ou despedaçados. Essa teoria decorre da experiência policial: se os autores de crimes de pequena gravidade são combatidos e perseguidos com eficácia pela polícia eles se sentem vencidos e fogem para outros locais onde possam cometer os crimes sem a intervenção da polícia.

4- PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE

Obs.: progressão e regressão de regimes; execução provisória; autorizações de saída; regras dos regimes; direitos e deveres do preso (trabalho do preso); remição; detração: serão estudados nas aulas de LEP.

4.1. Espécies

Existem a reclusão e a detenção cominadas para crimes e a prisão simples cominada para contravenções penais (art. 1º LICP).

4.2. Fixação do regime inicial

O regime inicial é fixado com fundamento em três fatores (art. 33, §§ 2º e 3º):

- a) quantidade da pena
- b) Reincidência
- c) circunstâncias judiciais

O STJ já decidiu que são esses os três fatores que o juiz deve considerar, **não podendo a gravidade abstrata do crime**, por si só, ser fator determinante exclusivo na fixação do regime inicial, uma vez que a gravidade abstrata já é considerada na quantidade de pena cominada (HC 97.656)

Em regra, é o juiz sentenciante que fixa o regime prisional. O juiz da execução também pode fixá-lo se durante a execução surgirem novas condenações.

Obs.:

1) O regime inicial obrigatoriamente fechado previsto na Lei de Crimes Hediondos foi declarado **inconstitucional** pelo STF que, contraditoriamente, reconheceu a constitucionalidade do regime inicial fechado na Lei de Tortura. O STJ entende que o art. 1º, § 7º da lei de Tortura é tão inconstitucional quanto o art. 1º, § 2º da LCH (AgRg no REsp 1977874/SP, 2022)

Atenção: o Pacote Anticrime criou hipótese de regime inicial obrigatório fechado para as lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição, uma vez que exige que o cumprimento da pena deve ocorrer em estabelecimento de segurança máxima.

2) o tráfico de drogas privilegiado não é considerado crime equiparado a hediondo, conforme habeas corpus coletivo concedido pelo STF e artigo 112, §5º da LEP alterado pelo Pacote Anticrime.

4.3. Pena de Reclusão

Pode ser iniciada em quaisquer dos três regimes.

Os critérios para determinar qual o regime aplicado são os seguintes:

- a) reincidente: regime inicial fechado qualquer que seja a pena. Atenção: Súmula 269 STJ.
- b) Primário: regime aberto nas condenações até 4 anos; semiaberto nas condenações superiores a 4 anos até 8 anos; fechado nas condenações superiores a 8 anos.

É possível a aplicação do regime mais severo do que o permitido pela pena aplicada desde que haja fundamentação idônea com base nas circunstâncias desfavoráveis do artigo 59 do CP. A gravidade abstrata do crime não serve de fundamento para essa aplicação (Súmulas 718 e 719 do STF)

4.4.) Pena de Detenção

Pode ser cumprida inicialmente nos regimes aberto e semiaberto.

Os critérios para determinação do regime são os seguintes:

- a) reincidente: regime inicial semiaberto qualquer que seja a quantidade de pena aplicada;
- b) primário: regime aberto na condenação até 4 anos e regime semiaberto na condenação superior a 4 anos.

Aplicam-se aqui a súmula 718 e 719 do STF.

Obs.: Pode ser cumprida em regime fechado em caso de regressão de regime.

4.5) Prisão simples

Cabível apenas nas contravenções penais.

- a) Deve ser cumprida sem rigor penitenciário em estabelecimento especial ou em seção especial de prisão comum
- b) deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto
- c) não pode ser cumprida em regime fechado nem por regressão de regime
- d) o condenado deve ficar obrigatoriamente separado dos condenados a penas de detenção e de reclusão.

Bloco 4

4.6.) Diferenças entre reclusão e detenção

Existem quatro diferenças fundamentais:

Reclusão	Detenção
1 - o regime inicial pode ser quaisquer um dos três	1 - o regime inicial só pode ser aberto ou semiaberto
2 - Havendo aplicação cumulativa de reclusão e detenção aplica-se primeiro aquela	2 - Idem.
3 - na reclusão pode haver o efeito da condenação da incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos.	3 - não existe esse efeito da condenação
4 - a reclusão acarreta internação em caso de imposição de medidas de segurança	4 - a detenção acarreta tratamento ambulatorial

Pergunta: *O juiz pode aplicar regime prisional mais rigoroso se fixar a pena-base no mínimo legal?*

Se a pena base foi fixada no mínimo legal isso significa que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis, razão pela qual não cabe regime prisional mais rigoroso.

É o entendimento amplamente majoritário inclusive sedimentado na Súmula 440 do STJ: “fixada a pena base no mínimo legal é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Pergunta: *O juiz da execução pode alterar o regime prisional fixado erradamente pelo juiz sentenciante?*

O Juiz de Execução não pode alterar o regime, o que acarretaria violação à coisa julgada e Revisão Criminal em desfavor do réu (STJ EREsp 1.738.968, 3ª Seção, 2019 e HC 654.870, 2022).

Obs.: independentemente da ordem de chegada das guias de recolhimento as penas mais graves devem ser sempre executadas antes das penas mais leves.

4.7. Aplicação da Pena Privativa de Liberdade

4.7.1. Ato judicial

A aplicação da pena é ato exclusivamente judicial.

Entretanto, é ato discricionário juridicamente vinculado, porque para calcular a pena o juiz está vinculado aos parâmetros e critérios estabelecidos pela lei. Dentro desses critérios o magistrado pode optar pela pena que entender mais adequada.

É a denominada teoria das margens.

4.7.2. Pressuposto

É a culpabilidade que exige imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Culpabilidade material.

4.7.3. Etapas na aplicação da pena

1ª Etapa: juiz fixa a quantidade de pena aplicada.

Existem 2 critérios: a) critério bifásico (Roberto Lyra, Frederico Marques e Basileu Garcia); b) critério trifásico (Nelson Hungria) que é o adotado pelo artigo 68 do CP.

Atenção: na pena de multa é adotado o critério bifásico (número de dias multa e valor de cada dia-multa)

Obs.: Alberto Silva Franco menciona uma quarta fase que é a substituição da prisão pela pena restritiva de direitos ou pecuniária.

Usando o critério trifásico do artigo 68 do CP.

- a) Pena-base (art. 59 do CP)
- b) Agravantes e atenuantes (artigos 61 a 65 do CP)
- c) Causas gerais e especiais de aumento e diminuição de pena

2ª Etapa : Juiz fixa o regime inicial prisional (art. 33 do CP)

3ª Etapa : Juiz verifica a possibilidade de:

- a) Substituir a prisão por penas restritivas de direitos e/ou pena de multa
- b) Suspende a execução da pena de prisão (*sursis*)

Obs.: O juiz ainda decidirá na sentença sobre a aplicação dos efeitos penais e extrapenais da condenação e sobre a manutenção ou revogação da prisão preventiva .

Estudando cada etapa:

1ª Etapa: juiz fixa a quantidade de pena aplicada usando o critério trifásico do artigo 68 do CP.

- a) *Pena-base (art. 59 do CP)*

O juiz fixa a pena-base utilizando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP. Essas circunstâncias tem caráter residual ou subsidiário, ou seja, só podem ser valoradas quando já não constituem elementos ou circunstâncias do tipo penal, sob pena de *bis in idem*.

O art. 59 do CP prevê oito circunstâncias judiciais que devem ser devidamente analisadas e fundamentadas na sentença, sob pena de nulidade dela.

A falta ou inidoneidade da fundamentação na quantificação da pena base pode acarretar excesso de pena com o necessário redimensionamento pela instância superior ou mesmo decretação de nulidade da sentença.

O STF e o STJ entendem que se a pena base for fixada no mínimo previsto não é necessária fundamentação.

O STF entende que a pena-base deve respeitar o princípio da proporcionalidade devendo haver uma relação lógica entre o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e a elevação da pena acima do mínimo.

Obs.: A pena-base não pode ser fixada aquém do mínimo previsto ou acima do máximo previsto, por mais favoráveis ou desfavoráveis que sejam as circunstâncias judiciais.

No crime qualificado a pena base deve partir da pena qualificada. Havendo duas ou mais qualificadoras o juiz deve agir da seguinte forma:

- a) utilizar uma qualificadora para aplicar a pena qualificada e as demais como agravantes genéricas, desde que previstas como tais nos artigos 61 e 62 do CP;
- b) utilizar uma qualificadora para aplicar a pena qualificada e as demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis se elas não estiverem previstas como agravantes genéricas.

As Circunstâncias judiciais:

Havendo uma só circunstância judicial desfavorável o juiz já deve fixar a pena base acima do mínimo previsto.

O juiz não é obrigado a indicar individualmente cada uma das circunstâncias judiciais que foram utilizadas para aumentar a pena base podendo se referir a elas genericamente (STJ (HC 501.144)

As circunstâncias judiciais são as seguintes:

1ª) Culpabilidade

A culpabilidade é pressuposto da aplicação da pena e não da quantificação da pena. Já o grau de culpabilidade indica qual a quantidade da pena-base a ser aplicada. Onde o artigo 59 menciona a culpabilidade o correto seria grau de culpabilidade.

2ª) Antecedentes

A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência (Súmula 636 STJ)

Inquéritos policiais e ações penais em andamento não configuram maus antecedentes, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (STF e súmula 444 do STJ)

A transação penal e a suspensão condicional do processo ou o acordo de não persecução penal também não configuram maus antecedentes.

O que são **maus antecedentes**?

Condenações definitivas que não acarretam reincidência (ou porque a reincidência já prescreveu, ou porque a condenação anterior é por crime militar próprio ou político, ou porque a condenação definitiva é por crime praticado antes da condenação definitiva por outro crime)

O STF já decidiu que vigorará o sistema da perpetuidade no caso de maus antecedentes, ou seja, uma condenação definitiva é apta a ensejar por tempo indeterminado os maus antecedentes não estando sujeito ao prazo de 5 anos aplicado à reincidência (STF, RE-RG 593.818, j. 17.08.2020 e RHC 207471Agr, 2022). O STJ também entende desta forma, mas os maus antecedentes devem ser valorados de acordo com o princípio da proporcionalidade levando em conta o lapso de tempo desde o cometimento do crime (STJ AgRg no HC 810030/SP, 26.05.2023)

Só pode ser reconhecido como mau antecedente o crime anterior ao crime no qual a circunstância judicial será aplicada já que se trata de “antecedente”. Entretanto, o trânsito em julgado da condenação por esse crime anterior pode ser posterior ao crime no qual será aplicado o mau antecedente (STJ AgRg no ARESP 243.109 e STF HC 117.737)

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), fixada no RE n. 593.818/SC, estabelece que o prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal não se aplica ao reconhecimento de maus antecedentes, não havendo prazo para “esquecer” condenações anteriores”. (STJ, AgRg no HC 868557 / SP, 12.12.24)

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, “quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento. (AgRg no HC n. 613.578/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/3/2021)”. (STJ, AgRg no HC 885100 / SC, 05.04.24)

“Os maus antecedentes foram reconhecidos, pois as condenações tiveram suas penas extintas há menos de 10 anos da data do crime apurado no presente caso (23/7/2020), sendo aptas, portanto, a negatar o vetor dos antecedentes, fazendo com que não seja aplicável, em relação a elas, o direito ao esquecimento”. (STJ, AgRg no HC 937977 / PR, 14.02.25)

Só pode ser reconhecido como mau antecedente o crime anterior ao crime no qual a circunstância judicial será aplicada já que se trata de “antecedente”. Entretanto, o trânsito em julgado da condenação por esse crime anterior pode ser posterior ao crime no qual será aplicado o mau antecedente (STJ AgRg no ARESP 243.109 e STF HC 117.737)

3ª) Conduta social

Também conhecida como antecedentes sociais, é o estilo de vida do réu perante a sociedade, família, trabalho, vizinhança etc.

O STJ entende que fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser valorados negativamente como culpabilidade, personalidade, ou conduta social desfavoráveis (HC 189.385 e HC 332.040).

O STF/STJ entende que o mesmo fato não pode ser valorado como conduta social e mau antecedente, sob pena de *bis in idem*.

4ª) Personalidade do agente

É o perfil subjetivo do réu nos aspectos moral e psicológico.

Essa análise não depende de laudo técnico especializado podendo ser valorada pelo juiz com base nas provas dos autos (STJ, (AgRg no Resp 1.802.881).

5ª) Motivos do crime

Os motivos do crime só podem ser considerados circunstâncias judiciais quando não configurarem elementar ou circunstância do delito. Por exemplo, o motivo fútil ou torpe já configura agravante ou causa de aumento em alguns delitos razão pela qual não podem ser utilizados nesses crimes como circunstância prejudicial desfavorável.

O dolo e a culpa também não podem ser valorados como motivos do crime uma vez que são elementos de todo e qualquer crime.

6ª) Circunstâncias do crime

São os meios ou modos de execução do crime, os instrumentos utilizados no crime, as condições de tempo e local , o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.

Também só poderão configurar circunstâncias judiciais na dosimetria da pena se não configurarem elementos ou circunstâncias do crime.

A gravidade abstrata do crime não pode ser considerada como circunstância do delito porque já é valorada pelo legislador no momento da cominação da pena.

7ª) Consequências do crime

Conforme STJ essas consequências podem ser para a vítima, seus familiares, ou até mesmo para a coletividade.

O STF e STJ entende que consequências lógicas do próprio crime não podem ser utilizadas como circunstância judicial desfavorável. Por exemplo o juiz não pode alegar que o crime de roubo com arma de fogo causou muito temor na vítima pois essa já é uma consequência do delito; ou que o crime de furto causou como consequência a diminuição do patrimônio da vítima.

Aliás consequências que são imanentes ao crime, ou seja, que são decorrências lógicas dele não podem ser valoradas como circunstâncias judiciais negativas. Por exemplo, o STF já decidiu que os elevados custos da atuação estatal para a apuração do crime e o enriquecimento ilícito do agente não são motivações idôneas para a consideração de consequências do crime.

Exemplo de consequência do crime que pode ser valorada: o exaurimento nos crimes formais, como por exemplo, o recebimento da vantagem indevida no crime de concussão.

8ª) Comportamento da vítima

O STJ decidiu que o comportamento da vítima só pode ser considerado como circunstância judicial favorável ao infrator, jamais desfavorável. Se é uma circunstância neutra, ou seja, que não interferiu em nada no crime, não pode ser considerada circunstância judicial desfavorável.

Exemplo: concorrência de culpas nos acidentes de trânsito.

1ª Etapa: juiz fixa a quantidade de pena aplicada usando o critério trifásico do artigo 68 do CP.

b) Agravantes e atenuantes

As agravantes estão em rol exaustivo enquanto as atenuantes estão em rol exemplificativo (art. 66 do CP).

O artigo 66 do CP permite as chamadas atenuantes inominadas que podem ser qualquer circunstância relevante e favorável ao réu anterior ou posterior ao crime. Ex. coculpabilidade.

As atenuantes e agravantes são de aplicação compulsória pelo juiz, que não pode deixar de aplicá-las. No tribunal do júri as agravantes e atenuantes não são questionadas aos jurados, mas aplicadas diretamente pelo juiz.

As agravantes e atenuantes não podem alterar os limites mínimo e máximo de pena cominados no tipo penal, razão pela qual serão inócuas se a pena base é aplicada no mínimo ou no máximo previsto (Súmula 231 do STJ; STF RE 597.270 e STJ AgRg no AgRg no HC 758457/GO, 2023)

Prevalece o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que as agravantes genéricas do artigo 61, II, do CP aplicam-se aos crimes doloso e preterdolosos, mas não se aplicam aos crimes culposos. Embora exista precedente do STF de que elas se aplicam aos crimes culposos (HC 70362, 1995)

O CP não estabelece o patamar de aumento ou diminuição de pena em razão das agravantes e atenuantes, mas prevalece o entendimento de que deve ser de 1/6 sobre a pena base por se tratar do menor índice previsto na lei para as causas de aumento e de diminuição de pena. Em circunstâncias excepcionais essa fração pode ser superior a 1/6, desde que exista motivação idônea em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime (STF, RHC 127.382, 2020).

STJ TEMA 1172: Tese: "A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso."

Bloco 5

b.1.) Agravante da reincidência (art. 61, I, do CP)

O STF já decidiu que a agravante da reincidência é constitucional não havendo que se falar em *bis in idem* (STF, RE 453.000).

Só existe reincidência quando o novo crime é praticado depois do trânsito em julgado da condenação anterior por outro crime.

Não existe reincidência se: a) o novo crime é cometido na data do trânsito em julgado do crime anterior; b) se o agente pratica dois crimes na mesma data que, são julgados na mesma sentença; c) se a denúncia ou queixa não indica a data na qual foi cometido o crime posterior (STJ, HC 200.900).

O indivíduo pode possuir inúmeras condenações e ainda assim ser primário desde que todos os crimes tenham sido praticados antes de alguma condenação definitiva.

A condenação anterior transitada em julgada pode ser por crime praticado no Brasil ou no estrangeiro e pode ser sentença proferida no Brasil ou no estrangeiro. A sentença estrangeira sequer precisa ser homologada no Brasil para gerar reincidência (art. 9º do CP).

Se a sentença condenatória for desconstituída judicialmente desaparecerá a reincidência.

O artigo 63 do CP dispõe que: “verifica se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

Dispõe o artigo 7º da LCP que: “verifica se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime, ou no Brasil por motivo de contravenção”

Então:

1ª - Condenação definitiva no Brasil ou no exterior pela prática de crime e prática de novo crime: reincidente

2ª - Condenação definitiva no Brasil ou no exterior pela prática de contravenção penal e prática de crime: primário

3ª - Condenação definitiva no Brasil ou no estrangeiro por crime e prática de contravenção: reincidente

4ª - Condenação definitiva no estrangeiro por contravenção e prática de nova contravenção: primário

5ª - A condenação definitiva no Brasil por contravenção e prática de nova contravenção: reincidente.

Pergunta: *Os atos infracionais servem como pressuposto da reincidência?*

“Atos infracionais não configuram crimes e, por isso, não é possível considerá-los como maus antecedentes nem como reincidência, até porque fatos ocorridos ainda na adolescência estão acobertados por sigilo e estão sujeitos a medidas judiciais exclusivamente voltadas à proteção do jovem” (STJ, HC 338.936).

Pergunta: *Condenação por multa acarreta reincidência?*

A reincidência existe independentemente de qual foi a pena aplicada no crime anterior (prisão, restritivas de direitos, multa). Existe entendimento na doutrina de que a pena de multa não acarretaria reincidência pois: a) é penalidade de pouca importância sem força para ocasionar reincidência; b) o artigo 77 do CP prevê que pena de multa não impede o *sursis*.

Pergunta: *Condenação pelo crime do art. 28 da lei 11.343/06 acarreta reincidência?*

O STJ já decidiu que a condenação pelo crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006 não acarreta reincidência (STJ, HC 453.437). Como contravenção penal não gera reincidência na prática de crime, soa desproporcional considerar que a infração do artigo 28 gera reincidência. É o mesmo entendimento do STF: “*Viola o princípio da proporcionalidade a consideração de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei 11.343/2006, ‘porte de droga para consumo pessoal’, para fins de reincidência*”. (RHC 178.512, 22.03.22)

Prova da reincidência:

1ª) Qualquer documento hábil que comprove a condenação anterior transitada em julgada, como por exemplo, folha de antecedentes e informações extraídas dos sites dos tribunais. **(corrente que prevalece)**

Súmula 636 do STJ: “A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”

2ª) Somente a certidão expedida pelo cartório judicial.

Espécies de reincidência:

Reincidência real, própria, verdadeira: ocorre quando o agente comete novo crime depois de ter cumprido integralmente a pena imposta no crime anterior.

Reincidência presumida, ficta, imprópria, falsa: quando o agente pratica novo crime depois da condenação anterior ainda que não tenha cumprido a pena imposta. É a adotada no Código Penal.

Reincidência genérica: os crimes não estão no mesmo tipo penal.

Reincidência específica: os crimes estão no mesmo tipo penal.

No Brasil, em regra, os efeitos da reincidência genérica e da reincidência específica são os mesmos. Mas existem exceções: é vedada a pena restritiva de direito aos reincidentes específicos; é vedado o livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos e equiparados.

“Prescrição” da reincidência:

O artigo 64, I, do CP dispõe que: “não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão do livramento condicional, se não ocorrer revogação”.

É o sistema da temporariedade (período depurador, ou caducidade).

Obs. note que o que “prescreve” é a reincidência. Quando se torna maus antecedentes, estes ficam para sempre (perpetuidade dos maus antecedentes)

Efeitos da reincidência:

- 1 – Na pena de reclusão impede o regime inicial aberto ou semiaberto e na pena de detenção impede o regime inicial aberto ;
- 2 – Nos crimes dolosos e impede a substituição da prisão por penas restritivas de direitos;
- 3 – No concurso com as atenuantes genéricas possui caráter preponderante (art. 67)
- 4 – no crime doloso impede o *sursis*, salvo se a condenação anterior foi a pena de multa .
- 5 – autoriza a revogação do *sursis*, do livramento condicional e da reabilitação, salvo se a condenação anterior foi de pena de multa.
- 6 – aumenta o prazo para a concessão do Livramento condicional nos crimes dolosos.
- 7 – impede o Livramento condicional nos crimes hediondos e equiparados se houver reincidência específica
- 8 – aumenta em 1/3 prazo da prescrição da pretensão executória.
- 9 – interrompe a prescrição da pretensão executória se for posterior à condenação.
- 10 – impede o reconhecimento do furto privilegiado, da apropriação indébita privilegiada, do estelionato privilegiado , da receptação privilegiada.
- 11 – impede a transação penal e a suspensão condicional do processo .
- 12 – autoriza a prisão preventiva quando o réu tiver sido condenado por outro crime doloso.
- 13 – impede o acordo de não persecução penal ;
- 14 – acarreta o indeferimento da Liberdade provisória na audiência de custódia (art. 310, § 2º, CPP)
- 15 – Aumenta o prazo para progressão de regime .

Crimes militares próprios e crimes políticos:

As condenações por crimes militares próprios (aqueles que estão tipificados exclusivamente no CPM e que só podem ser praticados por militares) e os crimes políticos que ofendem a segurança ou organização do estado) não acarretam reincidência (art. 64, II, CP), mas configuram maus antecedentes.

Atenção: crimes militares impróprios acarretam reincidência.

Reincidência e maus antecedentes

Súmula 241 do STJ: “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”

Atenção: Essa súmula se refere exclusivamente à mesma condenação. Se, entretanto, o indivíduo possui várias condenações uma delas pode ser utilizada como reincidência e a outra (s) como maus antecedentes.

De acordo com o STJ a outra condenação só pode ser utilizada como mau antecedente e não como conduta social ou personalidade negativa. Tema 1077: *“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”*. E ainda: AgRg no HC 788324/RJ, 20.04.23.

O reconhecimento equivocado da reincidência que acarrete prejuízo ao réu configura erro judiciário passível de indenização (STJ, Resp 1.243.516)

Ainda que, por lapso, a reincidência não seja aplicada na sentença condenatória, poderá ser utilizada pelo juiz das execuções para indeferimento de benefícios (EREsp 1.738.968)